

1503924-66.2019.8.26.0005

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... reincidência, referente ao crime de tráfico de entorpecentes - Gravidade do crime precedente que não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Regime intermediário bem fixado - Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0009069-08.2016.8.26.0451; Relator (a): Rodrigo Pares Andreucci; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

2ª Vara Criminal

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo-SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503924-66.2019.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503924-66.2019.8.26.0005

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Contravenções Penais

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3077217/2019 - 63º D.P. VILA JACUI, 6432957 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

Cesar Dias Serra

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

O réu, revel, não compareceu para ser interrogado.

A testemunha Gislene declarou que estava em patrulhamento, quando populares indicaram que havia máquinas caça niqueis no bar descrito na denúncia. Adentraram o bar e lá encontraram as máquinas desligas. A testemunha João Batista declarou não se recordar dos fatos.

De início, acerca da legitimidade dos depoimentos dos agentes públicos que presenciaram os fatos aqui narrados. Há muito tempo a jurisprudência pôs fim a essa questão ao decidir que:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma HC 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

No mais, em que pese a testemunha João Batista não se recordar dos fatos, a testemunha Gislene, diversamente do que aduzido nas alegações finais da defesa (fls. 119/120), foi firme em declarar que havia máquinas caça niqueis no bar mencionado na denúncia, de responsabilidade do acusado.

A materialidade veio provada pela prova pericial.

Da fl. 23 do laudo pericial produzido colhe-se que " a(s) máquina(s) examinada(s) no local já mencionado, quando operante(s) apresentava(m) – se, como equipamento(s) sorteador(es) aleatório(s) de resultados e, por conseguinte, o ganho ou perda, independem da habilidade física ou intelectual do apostador, trata-se, pois de equipamento(s) utilizado(s) para a prática de jogo de azar" – fl. 23 (grifo nosso)

Assim, da prova pericial, constata-se que as máquinas encontradas junto ao estabelecimento do réu possibilitavam a prática de jogo de azar, em que presente a álea como elemento determinante para o ganho ou a perda pelos jogadores. Não há, portanto, dúvida quanto à idoneidade do objeto para o fim contravencional. Nesse sentido, pontua-se que a contravenção penal prevista no artigo 50 do Decreto-Lei 3.688/1941 consiste na exploração de jogo de azar e não da propriedade da máquina. Dessa forma, a conduta descrita no tipo penal foi efetivamente praticada pelo acusado, já que permitiu a instalação de máquina destinada ao jogo de azar em seu estabelecimento.

No mais, a alegação de que as máquinas estavam desligadas no momento da constatação não socorre ao acusado, visto que, na fl. 22 do laudo pericial produzido, foi constatado que os equipamentos "(....) quando ligados, atuavam normalmente" (fl. 22).

Diante disso, observam-se demonstrados todos os elementos do tipo penal objeto da acusação, logrando-se comprovar que o réu estabeleceu jogo de azar, por permitir a instalação de máquinas caça-níqueis em funcionamento em seu estabelecimento, bar acessível ao público.

Dispensável para a configuração da contravenção que houvesse apostadores ou a demonstração de efetivas apostas, bastando, como se provou no caso vertente, que estivessem máquinas programadas para jogo de azar acessíveis ao público.

Nesse sentido a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR (LCP, ART. 50, CAPUT). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS E NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU QUE TINHA EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL MÁQUINA CAÇA-NÍQUEL À DISPOSIÇÃO PARA JOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO". (Apelação Criminal nº 2009.040244-5, de Balneário Camboriú. Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco. J. 19.05.2011) grifo nosso

"APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL. CAÇA NÍQUEL CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CONFIRMANDO QUE O LOCAL ERA DESTINADO A EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. APREENSÃO DE 21 (VINTE E UMA) MÁQUINAS DE CAÇA-NÍQUEL E ELEVADA QUANTIA EM, DINHEIRO. PROVAS DEMONSTRANDO QUE, DE FATO, AS MÁQUINAS APREENDIDAS ESTAVAM EXPOSTAS E EM PLENO FUNCIONAMENTO, FAVORECENDO O JOGO ILÍCITO. LOCAL ACESSÍVEL AO PÚBLICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NOS TERMOS DA LEI PENAL E LEVANDO-SE EM CONTA A QUANTIDADE DE MÁQUINÁRIO APREENDIDO. APENADO QUE JÁ POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS. INVIÁVEL A CONVERSÃO DO REGIME A ELE APLICADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO LAVRADO PELA POLÍCIA MILITAR. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SUAS RAZÕES E FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO". (STF.RE 979730, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 01/08/2016)

Ressalte-se, ademais, que, de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a contravenção penal descrita na demanda é delito de mera conduta, sendo irrelevante se as máquinas estavam desligadas ou desprovidas de numerários no momento em que apreendidas. Dessa forma, inexistente escusa defensiva apta a afastar a condenação.

Nesse sentido:

"Contravenção de Jogo de Azar (máquinas caça-níqueis) –Materialidade perfeitamente

demonstrada - O laudo pericial de fls. 06/141 é claro em dizer que, nas máquinas apreendidas, o ganho independe da habilidade do jogador, caracterizando, pois, jogo de azar - Autoria bem demonstrada - Recorrente que admitiu ser o proprietário do bar e que as máquinas estavam em seu interior - Policial que confirmou a apreensão das máquinas em seu estabelecimento - Fato de as máquinas estarem desligadas que não implica em "ausência de exploração do jogo" - Manobra corriqueira para tentar se eximir da responsabilidade penal - Máquinas em local de acesso ao público e que, para serem manuseadas, bastaria ser ligada na tomada de energia - Recorrente que já se viu envolvido na mesma atividade em outras oportunidades, conhecedor, pois, das consequências da manutenção das máquinas no estabelecimento comercial - Pena que merece reparo - Maus antecedentes que não podem prosperar, eis que a condenação que deu causa ao reconhecimento da majorante transitou em julgado posteriormente aos fatos aqui tratados - Pena que é arbitrada inicialmente em três meses de prisão simples mais o pagamento de dez dias-multa - Reprimenda acrescida em um sexto pela reincidência do acusado (fls. 84), resultando em três meses e quinze dias de prisão simples, mais onze dias-multa - Regime intermediário bem fixado pela reincidência, referente ao crime de tráfico de entorpecentes - Gravidade do crime precedente que não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Regime intermediário bem fixado - Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0009069-08.2016.8.26.0451; Relator (a): Rodrigo Pares Andreucci; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Piracicaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 19/01/2021; Data de Registro: 19/01/2021) grifo nosso

APELAÇÃO CRIMINAL - JOGOS DE AZAR (ART. 50, DO DECRETO-LEI Nº 3.668/41. EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS - Sentença absolutória - Recurso ministerial - Pretendida condenação do acusado nos exatos termos da denúncia - Possibilidade - Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas - Confissão extrajudicial que vem amparada em outros elementos de convicção amealhados durante a instrução -

Depoimento de policiais - Validade - Crime de mera conduta, sendo irrelevante que as máquinas estivessem desligadas e/ou sem dinheiro, já que tais condições não são exigidas pela lei, bastando apenas a destinação do equipamento ao jogo de azar - Sentença reformada - Condenação decretada - Pena fixada no mínimo legal, dada as circunstâncias judiciais favoráveis ao agente - Substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos - Cabimento - Preenchimento dos requisitos legais exigidos no art. 44, do Código Penal. Prescrição - Ocorrência -

Reconhecimento ex officio da prescrição da pretensão punitiva estatal - Decurso do interstício temporal entre o recebimento da denúncia e o presente julgamento - Sentença absolutória que não é considerada marco interruptivo do prazo

prescricional - Recurso ministerial provido e decretação ex officio da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. (TJSP;

Apelação Criminal 0008108-98.2011.8.26.0271; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/12/2015; Data de Registro: 18/12/2015) grifo nosso

"CRIMINAL - JOGO DE AZAR - ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/41 - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA DEMONSTRADA PELA ADMISSÃO DO RÉU DE QUE ERA A O PROPRIETÁRIO DO BAR E QUE LÁ HAVIA A MÁQUINA CAÇA-NÍQUEL APREENDIDA - POLICIAL CIVIL QUE FEZ A DILIGÊNCIA E TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA, QUE DISSE PRESTAR SERVIÇOS ESPORÁDICOS NO BAR, CONFIRMARAM A EXISTÊNCIA DA MÁQUINA NO ESTABELECIMENTO - POLICIAL ESCLARECEU QUE A MÁQUINA FICAVA NUM DEPÓSITO E QUE O LOCAL ERA ACESSÍVEL AOS CLIENTES - FATO QUE, POR SI SÓ, FAZ PRESUMIR A EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR PELO RÉU - INVEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DO RÉU, PESSOA EXPERIENTE E QUE JÁ FOI CONDENADA DIVERSAS VEZES PELA MESMA INFRAÇÃO, DE QUE TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO DEIXOU A MÁQUINA EM SEU ESTABELECIMENTO CONTRA SUA VONTADE - EVIDENTE QUE ELA FOI ALI COLOCADA PARA EXPLORAÇÃO DOS JOGOS DE AZAR PELO ACUSADO - IRRELEVANTE QUE, NO MOMENTO DA APREENSÃO, ELA ESTAVA DESLIGADA E SEM DINHEIRO - CONFORME ESCLARECEU O POLICIAL CIVIL, A AÇÃO POLICIAL FOI MOTIVADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA DA INFRAÇÃO NO LOCAL DOS FATOS E É MUITO COMUM, EM CASOS COMO ESSE, OS INFRATORES MANTEREM AS MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS DESLIGADAS, LIGANDO-AS SOMENTE QUANDO SÃO USADAS PELOS JOGADORES, PODENDO, INCLUSIVE, SER USADA EXTENSÃO ELÉTRICA PARA

QUE SEJA LIGADA EM TOMADA EXISTENTE EM CÔMODO ANEXO - MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PERICIAL DE FLS. 30/33, O QUAL FOI CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE A MÁQUINA APREENDIDA APRESENTA-SE COMO SORTEADORA ALEATÓRIA DE RESULTADOS E O GANHO OU PERDA INDEPENDEM DE CAPACIDADE FÍSICA OU MENTAL DO AGENTE, O QUE BASTA PARA A COMPROVAÇÃO DE QUE HAVIA EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR NO LOCAL - TIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, EIS QUE NÃO FOI CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO NA AÇÃO COM REPERCUSSÃO GERAL A RESPEITO DO TEMA A SER JULGADO PELO C. STF - CORRETA CONDENAÇÃO - RÉU PORTADOR DE PÉSSIMOS ANTECEDENTES (FLS. 44/48) E REINCIDENTE ESPECÍFICO (FLS. 46) - AUSÊNCIA DE ATENUANTES - PROBLEMAS DE SAÚDE DO RÉU NÃO CONSTITUEM ATENUANTES NEM CAUSAS DE ISENÇÃO DE PENA - PENA FIXADA EM 4 MESES E 2 DIAS DE PRISÃO SIMPLES E 13 DIAS-MULTA - PÉSSIMOS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA IMPÕEM A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL E IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - AUSÊNCIA DE "BIS IN IDEM" - RÉU NÃO ESTÁ PRESO POR ESTE PROCESSO, NÃO HAVENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER RECONHECIDO - QUESTÃO REFERENTE À VAGA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM REGIME FIXADO E EVENTUAL DIREITO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR EM RAZÃO DE PROBLEMA DE SAÚDE SÃO MATÉRIAS QUE CABEM AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO. ANA CLAUDIA MADEIRA DE OLIVEIRA JUÍZA RELATORA" (TJSP; Apelação Criminal 1514297-16.2018.8.26.0451; Relator (a): Ana Claudia Madeira de Oliveira; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Piracicaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020) (grifo nosso)

Passa-se, então, à dosimetria da pena.

O acusado é primário, sem mácula a seus antecedentes (fls. 35/37 e 42).

Observando a primariedade, os bons antecedentes, e que a conduta sob julgamento não excedeu a inerente gravidade abstrata antevista pelo legislador para cominar as penas, não se observa que possa sobrelevar a sanção do mínimo. Parte-se, portanto, nessa primeira fase da dosimetria, de três meses de prisão simples, além do pagamento de 10 dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Finalmente, na terceira etapa do procedimento de individualização da pena, inexistentes causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a sanção de pena de três meses de prisão simples, além do pagamento de 10 dias-multa.

Nos termos do art. 33, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade. Não há necessidade de imposição de regime mais gravoso. O réu é primário e não praticou o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, nada havendo que justifique uma segregação mais severa. Quanto à pena pecuniária, não tendo sido demonstrada condição financeira do réu que autorizasse a majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

No mais, encontram-se presentes as condições previstas pelo art. 44 do Código Penal. Trata-se de indivíduo primário, com bons antecedentes, que praticou conduta sem violência ou grave ameaça. Tudo isso somado ao montante da pena privativa de liberdade perfaz os requisitos legais, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, como disciplina o parágrafo 2º, do artigo 44, do Código Penal, consistente em prestação pecuniária de um salário mínimo, a ser revertida ao Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo.

Por fim, decido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório inicial para CONDENAR o réu Cesar Dias Serra, filho de Joao Cesar Dias Brasilino e de Maria Marinho de Figueiredo, inscrito no CPF/MF sob o n. 353.115.538-55, portador do RG n. 49595213, à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de prisão simples, em regime inicial aberto, e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 50, caput, do Decreto-lei 3.688/41. Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de um

salário mínimo nacional, no valor vigente ao tempo do fato, a ser revertida para o Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo.

Considerando o caráter da pena imposta, não há justificativa para a custódia cautelar. Reconheço o direito do réu de apelar em liberdade.

Determino, ademais, a destruição das máquinas apreendidas, caso tal medida ainda não tenha sido tomada. Oficie-se.

Sem custas na espécie, observando-se, ademais, que o réu é beneficiário da assistência judiciária gratuita, na medida em que assistido pela DPE e não demonstra gozar de posses incompatíveis com a pobreza.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em proveito do patrono dativo, no patamar máximo da tabela.

P.I.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA